

判例の立場に従って次のアからオまでの【事例】の甲の行為（乙に対する関係に限る。）について検討し、横領罪と背任罪の成否に関する後記の【結論】ⅠないしⅢに分類した場合、各事例とその結論の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、横領罪は業務上横領罪を含むものとする。

【事例】

ア. 甲は、自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後、所有権移転登記をしない間に、乙に無断で、借金をしている丙のため、その不動産に抵当権を設定して登記を完了した。

イ. 甲は、乙から、乙がAに金員を貸し付けて質物として交付を受けたA所有の高級腕時計の鑑定を頼まれ、乙のためにその時計を保管していたが、Aから返還を求められたことに応じ、乙に無断で、その時計をAに交付した。

ウ. 乙株式会社では、開発したコンピュータプログラムは乙会社の顧客にだけ使用させるとの内規があったにもかかわらず、そのプログラムを自己のCD-ROMで管理していた乙会社営業課長甲は、内規に違反し、乙会社の顧客ではない知人Aの依頼に応じ、乙会社に無断で、そのCD-ROMを社外に持ち出して、プログラムをA方のコンピュータに入力した。

エ. Aは、自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後、所有権移転登記をするまでの間に、その不動産を更に甲に売却しようとしたところ、甲は、Aがその不動産を既に乙に売却済みかもしれないとの未必的な認識を有しながら、この点を確認しないまま、Aからその不動産を購入して登記を完了した。

オ. 甲は、乙に対する債務の担保として、乙のため、自己の所有する不動産に抵当権を設定したが、抵当権設定登記をしない間に、乙に無断で、借金をしている丙のため、その不動産に一番抵当権を設定して登記を完了した。

【結論】

- Ⅰ. 横領罪が成立する。
- Ⅱ. 背任罪が成立し、横領罪は成立しない。
- Ⅲ. 横領罪も背任罪も成立しない。

1. アⅠ－イⅠ 2. アⅡ－ウⅢ 3. イⅢ－エⅡ 4. ウⅡ－オⅠ
5. エⅢ－オⅡ

No312	横領罪と背任罪		正答率
H18-5	正 解	5	72%

各事例とその結論の組合せは、ア＝Ⅰ、イ＝Ⅱ、ウ＝Ⅱ、エ＝Ⅲ、オ＝Ⅱである。よって、結論の組合わせとして正しいものは、エⅢ－オⅡであり、したがって、正解は肢5となる。

【事例と結論の組合せについて】

ア Ⅰ

不動産を乙に売り渡し代金を受け取った甲が、登記名義が残っていることを奇貨として、丙のために抵当権を設定しその登記を行った本事例において、甲に横領罪（252条1項）が成立するか。この点、不動産の二重売買については、通説、判例は通常、売主に横領罪の成立を認める（最判昭30.12.26）。「占有」（252条1項）には、事実上の占有のみならず、法律上の占有も含まれ、不動産の所有権は売買の意思表示により買主に移転しているから、売主は他人の不動産を登記簿上占有していることになり、これは買主の委託を受けて占有していることになるからである。そして、抵当権の設定等、委託物の担保供用は、所有権そのものの移転ではないが、行為者は金融の利益を受けるとともに、被担保債権が弁済されないときは、換価処分を受けざるを得ないから、これが横領に当たることには異論がない。判例も、他人に譲渡した不動産が登記簿上いまだ自己の所有名義となっていることを奇貨として、その不動産につき抵当権を設定してその旨の登記をした場合に、横領罪の成立を認めている（最判昭31.6.26）。よって、判例の立場に従えば、甲の行為には乙に対する横領罪が成立する。したがって、アの結論として正しいものはⅠとなる。

イ Ⅱ

質権者乙から鑑定を頼まれて保管していた高級腕時計について、保管者である甲が乙に無断で債務者Aに返還した行為につき、いかなる犯罪が成立するか。この点、判例（大判明44.10.13）は、債権者から、債務者より受け取った債務者所有の質物の保管を依頼された者が、債務者の要請を受け、ほしいままに同人にこれを返却したという事例イと類似の事案について、横領罪に当たるとした原判決を、所有権の侵害があったのではなく債権者の質権を侵害したにすぎないとして、破棄し、背任罪の成立を認めた。よって、判例の立場に従えば、甲の行為には乙に対する背任罪が成立する。したがって、イの結論として正しいものはⅡとなる。

ウ Ⅱ

コンピュータプログラムを自己のCD-ROMで管理する甲が、内規に違反し、A方のコンピュータにプログラムを入力する行為につきいかなる犯罪が成立するかが問題となる。この点、背任罪（247条）が成立するには、①他人のためその事務を処理する者（事務処理者）が、②図利・加害目的で、③任務違背行為を行い、④財産上の損害を生ぜしめることが必要である。そして、甲は乙社の営業課長としてプログラムを管理しているところ（①）、Aの利益を図る目的で（②）、内規に違反してAのコンピュータにプログラムを入力し（③）、プログラム入力代金相当額の損害を乙社に与えている（④）から、背任罪が成立する。なお、事例ウ類似の事案において、被告人に背任罪の成立を認めた下級審判例がある（東京地判昭60.3.6、総合コンピューター事件）。したがって、ウの結論として正しいものはⅡとなる。

エ III

Aが不動産を乙に売却した後、自己に登記名義が残っていることを奇貨として、甲に同一不動産を売却した場合、Aに横領罪が成立する。では、甲が悪意の場合、甲がAの横領罪の共同正犯になるか。これについて、判例は否定する（最判昭31.6.26）。これは、民法理論において、Cが単純悪意にとどまる場合には、なお民法177条の「第三者」に当たり、Cは民法上有効に所有権を取得できると解されていることとの整合性を図るものといえよう。そうだとすれば、仮にCが同条の「第三者」に当たらない背信的悪意者の場合には、Cは民法上有効に所有権を取得しないから、Aの共犯として処罰してもよいという結論が導かれよう（福岡高判昭47.11.22、百選Ⅱ65事件）。本事例についてみるに、「甲は、Aがその不動産を既に乙に売却済みかもしれないとの未必的な認識を有しながら、この点を確認しないまま、Aからその不動産を購入して登記を完了した」とあるので、甲は悪意といい得るものの、背信的悪意者と評価することはできない。そうすると、甲に横領罪の共同正犯は成立しない。また、甲は乙に対して何ら義務を負っておらず、背任罪（247条）も成立しない。よって、甲の行為は、乙に対する横領罪も背任罪も成立しない。したがって、エの結論として正しいものはⅢとなる。

オ II

自己所有の不動産に、乙に対して抵当権を設定した甲が、その抵当権設定登記をしない間に、同一不動産につき丙に一番抵当権を設定しその登記を完了した場合、甲にいかなる犯罪が成立するか。債権者に抵当権を設定した者が、その者に対する抵当権の設定登記をする前に、他者に別個に抵当権を設定し登記も完了してしまう二重抵当は、二重売買と異なり背任罪の成否が問題とされる。一般に行為者は最初の抵当権者に対し登記に協力する義務を負うと解される。そこで、登記に必要な書類等を引き渡す協力行為を行う以前に、別個の抵当権を設定しそれを先に登記する行為は、任務違背行為といえよう（最判昭31.12.7、百選Ⅱ70事件）。本事例についてみるに、乙に対する抵当権設定登記をしない間に丙に対する抵当権を設定し登記していることから、甲に背任罪が成立する。したがって、オの結論として正しいものはⅡとなる。